

## <제12장 단체교섭.제01절 단체교섭의 당사자>

[기출][2][2009-1]도급 또는 파견 계약 관계에서 노조법상 사용자로서 단체교섭 의무 부담 여부

《【문제1】 A회사는 종전까지는 직접 수행하던 업무의 일부를, B회사와는 도급계약을 통해, C회사와는 근로자파견계약을 통해 각각 외주화하였다. B회사 근로자로 조직된 甲 노동조합과 C회사 근로자로 조직된 乙 노동조합이 각각 A회사를 상대로 단체교섭을 요구하였으나, A회사는 직접근로관계가 없다는 이유로 단체교섭을 거부하였다. 이에 甲·乙 노동조합은 단체교섭거부를 이유로 한 부당노동행위구제신청을 하였다. A회사의 부당노동행위 책임에 대하여 논하시오. (50점)》

### <문제1> 도급 또는 파견 계약 관계에서 노조법상 사용자로서 단체교섭 의무 부담 여부

#### I. 문제 제기

- 본 사안은 A회사가 종래 직접 수행하던 업무를 B회사(도급)와 C회사(근로자파견)를 통해 외주화한 상황에서, B회사 소속 근로자로 조직된 甲 노동조합과 C회사 소속 근로자로 조직된 乙 노동조합이 각각 A회사를 상대로 단체교섭을 요구하였으나, A회사가 직접적인 근로관계가 없다는 이유로 이를 거부한 상황이다. 쟁점으로 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법')상 <단체교섭의 의무를 부담하는 사용자 범위가 외주화 형태(도급 또는 파견)에 따라 어떻게 달라지는지>, <A회사가 B회사 근로자(도급) 및 C회사 근로자(파견)에 대하여 각각 노조법상 사용자로서 단체교섭 의무를 부담하는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 A회사의 단체교섭 의무 부담 여부에 따른 부당노동행위 책임에 대하여 논한다.

#### II. 도급계약의 경우 단체교섭의무 관련 사용자 범위

- 도급계약은 원칙적으로 도급인(A회사)과 수급인(B회사) 사이의 기업 대 기업 관계이며, 수급인 근로자(甲 노동조합 조합원)에 대한 직접적인 근로계약 관계는 수급인(B회사)에게만 존재한다. 따라서 단체교섭 의무를 부담하는 사용자는 원칙적으로 B회사이다.

##### 1. 원칙적인 사용자 개념

- 노조법 제2조 제2호의 사용자는 근로계약의 당사자인 사업주를 일컫는다. 도급계약에 있어 B회사가 甲 노동조합 조합원과 근로계약을 체결한 사업주이므로, 원칙적으로 B회사만이 노조법상 사용자에 해당하며 단체교섭 의무를 부담한다. A회사는 甲 노동조합에 대하여 단체교섭 의무를 부담하지 않는다.

##### 2. 예외적인 사용자 개념 (단체교섭의무 확대)

- 대법원은 도급 형태의 외주화 과정에서 원청업체(A회사)가 하청업체(B회사) 근로자들의 핵심적인 근로조건에 대하여 실질적이고 구체적인 지배·결정 권한을 행사하는 경우에는, A회사에게 예외적으로 노조법상 사용자성을 인정하고 단체교섭 의무를 부과하는 지배·결정설 법리를 확립하였다. 판단 기준은 단체교섭의 대상이 되는 근로조건이 하도급인(B회사)에게 독자적인 처분 권한이 있는지 여부를 중심으로, 원청(A회사)의 실질적인 영향력 행사를 다음의 요소들을 종합하여 판단한다.

##### (1) 하도급 근로자 근로조건에 대한 실질적·구체적 관여 여부

- 핵심적인 판단 기준이다. A회사가 甲 노동조합 조합원의 임금, 근로시간, 복지 등 핵심 근로조건을 직접적 또는 간접적으로 결정하거나 지배할 수 있는 지위에 있는지가 중요하며, 이는 하도급 계약의 내용, 거래 관행 등을 통해 판단된다. 단순히 경영상 영향력을 행사하는 것을 넘어, 노사 교섭을 통해 결정되어야 할 사항에 대한 처분 권한이 있는지 여부가 핵심이다.

##### (2) 인사 관련 사항 관여 여부

- A회사가 甲 노동조합 조합원의 채용, 징계, 배치, 해고 등 인사 관련 사항에 대하여 B회사의 의사를 무력화시킬 정도로 강력하게 관여하는지 여부가 고려된다.

##### (3) 작업 수행 지휘·감독 여부

- A회사가 B회사 근로자에게 구체적이고 개별적인 업무 지시를 내리는지 여부가 판단 요소가 된다. 다만, 이는 근로기준법상 사용자 판단의 주된 요소이며, 노조법상 단체교섭 사용자성 판단에서는 근로조건 결정력보다 보조적인 요소로 활용된다.

##### (4) 사업의 독립성 결여 여부

- B회사가 A회사에 전적으로 의존하는 정도가 높아 사업의 독립성이 결여되어 사실상 A회사의 노무 관리 조직의 일부처럼 기능하는지 여부가 고려될 수 있다.

##### (5) 시설, 장비 등의 제공 여부

- A회사가 B회사 근로자들의 작업을 위한 주요 생산 시설, 장비, 원자재 등을 제공하고, B회사가 A회사의 사업장 내에서 전적으로 업무를 수행하는지 여부도 실질적인 지배력 판단의 근거가 된다.

##### (6) 단체교섭 대상 근로조건에 대한 처분 권한 여부

- 가장 중요한 요소로서, 교섭 대상 사항에 대한 결정 권한이 B회사에 있는 경우(예 : B회사 자체의 복지 제도)에는 A회사의 단체교섭 의무가 부정된다. 그러나 A회사가 사실상 임금 테이블을 결정하거나, B회사의 경영 상태를 고려할 때 A회사의 용역 대금 없이는 임금 인상 등이 불가능한 경우와 같이 하도급인이 단체교섭 사항에 대한 처분 권한을 실질적으로 가지지 못하는 경우에 한하여 A회사의 사용자성이 인정된다.

#### III. 근로자파견계약의 경우 단체교섭의무 관련 사용자 범위

- 근로자파견계약은 파견근로자보호 등에 관한 법률(이하 '파견법')에 의해 규율되며, 근로계약 당사자와 실제 노무 제공을 받는 사업주가 분리되는 특수한 관계이다.

##### 1. 원칙적인 사용자 개념

##### (1) 파견사업주(C회사)

- 파견사업주(C회사)는 파견 근로자(乙 노동조합 조합원)와 근로계약을 체결한 당사자이므로, 노조법상 명시적인 사용자에게 해당한다. C회사는 고용, 임금 지급, 사회보험 등 근로계약상 의무를 부담하며, 乙 노동조합에 대하여 단체교섭 의무를 부담한다.

##### (2) 사용자사업주(A회사)

- 사용자사업주(A회사)는 파견 근로자에게 업무 지시 및 명령을 내리고 작업 환경을 관리하는 주체이며, 파견법상 사용자로서의 의무(차별 금지, 안전 보건 등)를 부담한다. 다만, 노조법상 단체교섭 의무와 관련하여서는 그 범위가 제한된다.

##### 2. 파견근로관계에서의 사용자 개념 (노조법상)

- 파견근로관계는 이미 파견법에 의해 사용자사업주(A회사)와 파견사업주(C회사)의 권한 및 의무가 법정화되어 있으므로, 도급과 달리 예외적인 사용자 개념 확대 법리(지배·결정설)의 적용이 제한된다는 것이 일반적인 견해이다.

### (1) 파견사업주(C회사)

- C회사는 근로조건의 결정권과 근로계약상의 주된 책임을 지고 있으므로, 乙 노동조합에 대한 주된 단체교섭 의무를 부담하는 사용자이다.

### (2) 사용자사업주(A회사)

- A회사는 파견 근로자의 노무 제공 과정을 지휘·감독하는 실질적 사용자이지만, 파견법에 의해 이미 근로조건의 주요 사항(임금, 휴일 등)은 C회사가 부담하는 것이 법정화되어 있다. 따라서 A회사는 乙 노동조합에 대하여 노조법 제81조 제3호의 단체교섭 거부 사용자로 인정되기는 어렵다는 것이 통설 및 판례의 태도이다. A회사는 乙 노동조합과의 교섭이 불필요한 노사관계의 혼란을 야기할 수 있다는 이유로 거부할 정당성을 가진다.

### (3) 부당노동행위 책임

- A회사의 부당노동행위 책임은 단체교섭 거부(제81조 제3호)보다는 지배·개입(제81조 제4호) 또는 불이익 취급(제81조 제1호)에 국한되어 인정된다. 즉, A회사가 乙 노동조합의 조직 또는 운영을 지배·개입하거나, 乙 노동조합 활동을 이유로 C회사 소속 근로자에게 불이익을 주는 경우에 부당노동행위 책임이 발생한다. 단순한 단체교섭 거부만으로는 노조법 제81조 제3호 위반의 부당노동행위 책임이 인정되지 않는다.

## IV 사안의 적용

### 1. B회사(도급) 근로자 甲 노동조합의 단체교섭 요구

#### (1) 사용자성 판단

- A회사가 B회사 근로자(甲 노동조합 조합원)에 대하여 노조법상 사용자로서 단체교섭 의무를 지는지는 A회사가 甲 조합원의 핵심 근로조건 결정에 실질적이고 구체적인 지배·결정 권한을 행사하는지 여부에 달려있다. 만약 A회사가 B회사와의 도급계약을 통해 사실상 B회사 근로자의 임금, 휴가 등 근로조건을 결정하고, B회사는 명목상의 사용자에게 불과하다면, A회사는 예외적인 간접 사용자로 인정된다.

#### (2) 부당노동행위 책임

- A회사가 위 요건(지배·결정력)을 충족하여 노조법상 사용자로 인정된다면, A회사가 甲 노동조합의 교섭 요구를 직접 근로관계가 없다는 이유만으로 거부한 행위는 정당한 이유 없는 단체교섭 거부해당하여 부당노동행위(노조법 제81조 제3호)가 성립한다.

### 2. C회사(파견) 근로자 乙 노동조합의 단체교섭 요구

#### (1) 사용자성 판단

- 파견근로관계에서는 C회사(파견사업주)가 근로계약의 당사자이자 임금 지급 의무 등 주된 근로조건 결정권을 가지는 주된 사용자이다. A회사(사용사업주)는 노무 수령 및 지휘·명령 권한만 가지는 보조적 사용자의 지위에 있다. 파견법의 존재로 인해 도급과 같은 예외적인 지배·결정설의 확대 적용은 어렵다.

#### (2) 부당노동행위 책임

- A회사가 乙 노동조합의 단체교섭 요구를 거부한 것은, A회사가 乙 노동조합에 대하여 노조법 제81조 제3호의 단체교섭 의무를 부담하는 사용자 지위에 있지 않기 때문에, 원칙적으로 부당노동행위가 성립하지 않는다고 보아야 한다. 乙 노동조합에 대한 교섭 의무는 파견법상 주된 사용자인 C회사에게 있다.

## V 결론

### 1. 도급계약의 경우(甲 노동조합)

- 甲 노동조합에 대한 A회사의 부당노동행위 책임은 A회사가 B회사 근로자의 핵심 근로조건 결정에 실질적이고 구체적인 지배·결정 권한을 행사하는지 여부에 따라 결정된다.

#### (1) A회사에 지배·결정 권한이 있는 경우

- A회사는 노조법상 간접 사용자로서 단체교섭 의무를 부담하며, 교섭 거부해당하여 부당노동행위에 해당한다.

#### (2) A회사에 지배·결정 권한이 없는 경우

- A회사는 사용자가 아니므로, 교섭 거부해당하여 부당노동행위에 해당하지 않는다.

### 2. 근로자파견계약의 경우(乙 노동조합)

- 乙 노동조합에 대한 A회사의 단체교섭 의무는 원칙적으로 부정된다. A회사는 파견법상 사용사업주로서 파견 근로자에 대한 근로조건 결정권이 파견사업주(C회사)에게 주어져 있으므로, 노조법 제81조 제3호의 단체교섭 의무를 부담하는 사용자로 보기 어렵다. 따라서 A회사가 乙 노동조합의 교섭 요구를 거부한 것은 부당노동행위가 성립하지 않는다. 다만, A회사가 乙 노동조합 활동을 이유로 불이익을 주거나 지배·개입하였다면 별도의 부당노동행위(제81조 제1호, 제4호)가 성립할 수 있다.

### 3. 종합적 판단

- A회사의 단체교섭 거부 행위는 도급 계약(甲 노동조합)의 경우에는 A회사의 실질적인 지배·결정력 여부에 따라 부당노동행위 성립 여부가 갈리며, 근로자파견 계약(乙 노동조합)의 경우에는 A회사가 단체교섭 의무를 지는 사용자가 아니므로 원칙적으로 부당노동행위 책임이 없다.